

<제3편 제1심의 소송절차.제5장 소송 개시와 심리 대상.제3절 소의 이익>

I. 소의 이익의 의의

- 소의 이익이란 원고가 제기한 소가 법원의 판결을 받을 만한 가치와 필요성이 있는지를 의미한다. 이는 국가의 재판권이라는 한정된 자원을 낭비하지 않고, 부당한 소송으로부터 상대방을 보호하며, 구체적인 분쟁 해결에 실효성이 있는 경우에만 재판을 허용하겠다는 취지의 소송요건이다. 소의 이익은 크게 소송물이 재판에 적합한 대상인지를 판단하는 권리보호의 자격(대상적격)과 구체적으로 판결을 얻을 필요가 있는지를 판단하는 권리보호의 이익(협약의 소의 이익)으로 나뉜다.

II. 권리보호의 자격

1. 청구가 소구할 수 있는 구체적인 권리 또는 법률관계일 것

(1) 소구할 수 있는 것

- 소구할 수 있는 권리란 법원에 의해 강제적으로 실현될 수 있는 성질을 가진 것이어야 한다. 민사소송의 대상은 원칙적으로 사법상의 권리나 법률관계에 한정된다. 종교 단체의 내부 규율이나 단순한 도덕적 의무, 자연채무 등은 강제 이행을 구할 수 없으므로 소구할 수 없다.

(2) 구체적인 권리 또는 법률관계의 주장일 것

- 추상적인 법령의 해석이나 단순한 사실의 존부 확인은 소송의 대상이 되지 않는다. 반드시 당사자 사이의 구체적인 권리 의무에 관한 다툼이어야 한다. 학설이나 이론의 타당성 여부를 묻는 소송은 부적법하다.

(3) 법원의 권한에 속하는 법률상 쟁송일 것

- 헌법상 통치행위나 국회의 자율권에 속하는 사항 등 사법 심사가 제한되는 영역은 소구할 수 없다. 또한 행정처분의 무효나 취소를 민사소송으로 구하는 것과 같이 행정소송의 배타적 관할에 속하는 사항도 민사소송의 대상으로서의 자격이 결여된다.

2. 법률상·계약상 소제기 금지사유가 없을 것

(1) 법률상 소제기 금지사유가 없을 것

- 법률에 의해 일정 기간 소제기가 금지되거나 특정 절차를 거쳐야 하는 경우가 있다. 제소기간의 도과, 조정전치주의 위반 등이 이에 해당한다. 또한 변호사법 위반의 대리행위 등 공익적 사유로 소제기가 차단되는 경우도 포함된다.

(2) 계약상 소제기 금지사유가 없을 것

- 당사자 사이에 특정한 분쟁에 대하여 소를 제기하지 않기로 하는 부제소 합의가 있는 경우이다. 이러한 합의는 당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 권리에 관한 것이어야 하며, 방식이 명확하고 불공정하지 않아야 유효하다. 유효한 부제소 합의를 위반하여 제기된 소는 소의 이익이 없어 각하된다.

3. 재소장애사유가 없을 것

- 판결이 선고된 후 소를 취하한 자는 동일한 소를 다시 제기하지 못한다(민소법 제266조). 이는 법원의 판단을 농락하는 행위를 방지하기 위한 제도이다.

(1) 국·공유재산 관련 판례

- 국유재산의 무단 점유자에 대한 변상금 부과 처분 등 행정처분이 개입된 사안에서, 민사상 손해배상 청구와 행정상 변상금 청구가 병행될 때 재소 금지 원칙의 적용 범위에 유의하여야 한다.

(2) 부기등기 관련 판례

- 주등기가 취하되거나 말소된 경우 그에 의존하는 부기등기에 대하여 별도로 소를 제기하는 것이 재소금지에 해당하는지에 대하여, 판례는 등기의 독립성과 동일성을 기준으로 판단하여 절차적 안정을 도모한다.

4. 원고가 동일한 청구에 대하여 승소확정판결을 받은 경우가 아닐 것

(1) 원칙

- 원고가 이미 승소확정판결을 받았다면 다시 소를 제기할 이익이 없다. 중복된 판결을 방지하고 법원의 업무 과중을 막기 위함이다.

(2) 예외

- 다만, 판례는 소멸시효 중단을 위해 재소가 필요한 경우나 판결 내용이 불분명하여 집행이 불가능한 경우 등 특별한 사정이 있는 때에는 예외적으로 재소를 허용한다. 최근 판례는 시효중단을 위한 재소 시 새로운 방식의 확인소송 등을 인정하여 당사자의 편의를 도모하기도 한다.

5. 신의칙 위반의 재소가 아닐 것

- 신의성실의 원칙에 반하는 소제기는 권리남용에 해당하여 소의 이익이 부정된다. 모순행위 금지 원칙이나 실효의 원칙에 따라, 장기간 권리를 행사하지 않다가 갑자기 소를 제기하여 상대방의 정당한 신뢰를 저해하는 경우 등이 이에 해당한다.

III. 권리보호의 이익★

1. 이행의 소

(1) 현재이행의 소

- 이행기가 도래하였음에도 채무자가 이행하지 않는 경우이다. 원칙적으로 이행을 청구하는 것만으로 소의 이익이 인정되나, 채무자가 이행의 의사를 명확히 하고 이행할 준비가 되어 있는 등 다툼이 전혀 없는 경우에는 예외적으로 이익이 부정될 수 있다.

(2) 장래이행의 소

- 이행기가 장래에 도래하는 경우로서, 미리 청구할 필요가 있어야 한다(민소법 제251조). 채무자가 채무의 존재를 다투거나, 채무자의 태도에 비추어 이행기에 자발적 이행을 기대하기 어려운 경우에 인정된다. 판례는 부당이득 반환이나 불법행위로 인한 계속적 손해배상 청구 등에서 장래 발생할 금액이 확정적인 경우 이를 널리 인정한다.

2. 확인의 소

(1) 서설

- 확인의 소는 원고의 법적 지위에 현존하는 불안·위험이 있고, 확인판결이 이를 제거하는 데 가장 유효적절한 수단인 경우에 허용된다.

(2) 대상적격(권리보호자격)

- 확인의 대상은 현재의 법률관계여야 한다. 과거의 법률관계나 단순한 사실관계는 원칙적으로 대상이 될 수 없으나, 그것이 현재의 권리관계를 결정하는 전제가 되는 경우에는 예외적으로 허용되기도 한다.

(3) 확인의 이익(권리보호이익)

- 이행의 소를 제기할 수 있음에도 확인의 소를 제기하는 것은 방법의 선택에 있어 적절하지 않은 것으로 본다(확인소송의 보충성). 다만, 이행 청구만으로는 분쟁이 완전히 해결되지 않거나 피고가 다수여서 일률적인 확정이 필요한 경우에는 확인의 소가 허용될 수 있다.

(4) 증서의 진부 여부를 확인하는 소[민소법 제250조]

- 사실관계 확인임에도 법률이 예외적으로 인정한 경우이다. 서면의 작성자가 본인인지 여부 등에 대한 다툼을 미리 해결함으로써 법적 혼란을 방지하려는 목적이다.

3. 형성의 소

- 형성의 소는 법률에 명문의 규정이 있는 경우에만 허용되는 것이 원칙이므로, 그 요건 자체가 권리보호의 이익을 포함하고 있다. 법령이 정한 사유가 발생하였고, 판결을 통해서만 법률관계를 변화시킬 수 있는 경우에 소의 이익이 인정된다. 형성판결이 확정되면 그 효과는 제3자에게도 미치는 경우가 많으므로 법원은 형성권 행사의 요건을 엄격히 심사하여야 한다.

IV. 결론

- 소의 이익은 민사소송이 단순한 감정의 배출구나 이론적 유희의 장으로 전락하는 것을 방지하는 법적 장치이다. 권리보호의 자격이 소송의 문턱을 결정한다면, 권리보호의 이익은 그 문턱을 넘어야 할 실질적 필요성을 검증한다. 현대 소송법은 당사자의 권리 구제 범위를 확대하기 위해 장래이행의 소나 시효중단을 위한 재소 등을 전향적으로 검토하고 있으나, 동시에 신의칙 위반이나 부제소 합의 위반 등 부당한 소송에 대해서는 엄격한 잣대를 적용하고 있다. 법원은 개별 사건에서 소의 이익 유무를 면밀히 살핌으로써 사법 자원의 효율적 배분과 실질적 권리 보호라는 두 가지 가치를 조화롭게 실현하여야 할 것이다.